

1500772-61.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... específico, pois condenado definitivamente por roubo majorado e furto (autos n.º 0001966-77.2016.8.26.0635 - certidão de p. 38 e autos n.º 0003110-23.2015.8.26.0562 - certidão pp. 38/39).

Além disso, ostenta duas condenações definitivas antigas pelas práticas de roubo e furto qualificado (autos n.º 0036182-83.2011.8.26.0071 - certidão p. 40 e autos n.º

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500772-61.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500772-61.2022.8.26.0536 - Controle nº 187/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SANTOS BITENCOURT

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

RAFAEL SANTOS BITENCOURT, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta de 1h, na Rua Doutor Oswaldo Cruz n.º 319, bairro Boqueirão, neste município e comarca, de comum acordo e previamente ajustado com o corréu Ray Moraes, agindo com unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, subtraíram, para eles, uma folha de portão pertencente ao Súper Centro Boqueirão, bem esse avaliado R\$ 100,00 (pp. 13/14).

Diz a denúncia que, no desiderato de perpetrar ilícito patrimonial, o acusado e o corréu, previamente ajustados e com divisão de tarefas, dirigiram-se ao local para subtrair as folhas de portão de alumínio que guardam o hidrômetro do imóvel onde está estabelecido o Súper Centro do Boqueirão.

Ocorre que, o porteiro Américo, que ali trabalha, viu o acusado Rafael e o corréu Ray na parte externa do local em atitude suspeita, presenciando o momento em que puxavam o portão de alumínio.

Assim, em companhia de outro porteiro, dirigiram-se ao local. O porteiro Américo deteve o corréu Ray na esquina, na Rua Lobo Viana com Rua Alvares de Azevedo, de

posse de uma folha do portão. O acusado Rafael foi detido pelo porteiro Alex ainda na Rua Lobo Viana n.º 69, enquanto tentava subtrair a outra folha do portão, a qual ficou danificada.

Diz, por fim, a petição inicial que a Polícia foi acionada, compareceu ao local e conduziu o acusado e o corréu à congênera policial, local onde se reservaram o direito de permanecerem calados (pp. 95/96).

Recebida a denúncia (pp. 98/100), o acusado Rafael e o corréu Ray foram pessoalmente citados (p. 127). Oferecida a resposta de p. 131, prosseguiu-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 132/133). Na instrução foram ouvidos o representante da vítima e duas testemunhas, procedendo-se ao interrogatório do acusado Rafael (pp. 132/133).

Foi determinado o desmembramento do processo em relação ao corréu Ray, que se encontra solto, diante da impossibilidade de seu interrogatório na data marcada para audiência de instrução julgamento (pp. 373/375).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. Além disso, pugnou pelo aumento da pena-base em virtude dos maus antecedentes, bem como pelo reconhecimento da agravante da reincidência e sua preponderância em relação à confissão espontânea. Por fim, pleiteou a fixação de regime fechado para início do cumprimento de pena e a manutenção da prisão cautelar (gravação audiovisual, pp. 206/208).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações orais, pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância, diante do valor da res furtiva e da restituição do bem à vítima. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Ademais, pleiteou o reconhecimento da forma tentada do crime, uma vez que o acusado foi surpreendido ainda nas dependências da empresa. Por fim, pretendeu a fixação de regime prisional inicial intermediário (gravação audiovisual, pp. 206/208).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade está demonstrada no auto de exibição e apreensão pp. 13/14 e laudo pericial de pp. 196/202.

A autoria também é certa.

Ao ser preso em flagrante delito, o acusado Rafael manteve-se calado deixando de esclarecer as razões e circunstância de sua prisão (p. 8).

Em juízo, ao ser interrogado, afirmou que já foi preso e processado em três ocasiões pelo cometimento de assaltos. Os processos correram na capital do Estado e nas cidades de Lençóis Paulista e Bauru. Disse que nunca morou em Santos. Há quase dois anos estava em liberdade e veio para o litoral à procura de emprego. Conheceu o corréu Ray na região de Santos. Admitiu que praticou a conduta criminosa, relatando que estava na companhia do corréu Ray na região central da cidade e foram abordados por dois policiais. Ao constatarem seus maus antecedentes, os policiais ordenaram que deixassem a cidade. Disse que foram até a rodoviária na tentativa de conseguirem uma passagem para a cidade de São Paulo. Todavia, não tiveram sucesso. Assim, resolveram seguir no sentido da praia, para assim conseguir ajuda. No percurso, viram os portões de alumínio e os subtraíram. Afirmou que tentava retirar uma folha de alumínio, enquanto o corréu Ray já estava de posse da outra parte do portão. Contou que os dois vigilantes apareceram e pegaram o corréu Ray com uma folha do portão. Havia conseguido retirar a outra folha de alumínio, mas, quando viu os vigilantes, jogou-a sobre a grama. Afirmou que o vigilante Alex ordenou que recolocassem os portões no lugar e assim fizeram. Após terminarem de encaixar as duas folhas metálicas do portão, um outro vigilante chamou a Polícia. Com a chegada da viatura, um dos policiais, que não foi ouvido na audiência, afirmou que era necessário retirar o portão e levá-lo até a delegacia. Por este motivo, enviaram apenas uma das folhas metálicas. Informou que pretendia vender o alumínio para conseguir se alimentar e comprar as passagens de ônibus para ele e o corréu deixarem a cidade. Parte de sua família reside na zona leste da capital do Estado.

Demais familiares residem em Bauru, cidade onde morava com seus pais. Conheceu o corréu Ray em Santos e por acaso. Relatou que não trabalhou enquanto esteve em liberdade na cidade de São Paulo. Deslocou-se da capital até Santos de carona. Tem uma filha com 15 anos de idade que reside com a mãe. Kursou o Ensino Fundamental. É viciado em álcool e lança-perfume. Afirmou que está arrependido. Praticou o crime em situação de desespero por ter se sentido ameaçado pela Polícia (gravação audiovisual, pp. 206/208).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

Américo Jorge de Oliveira Neto disse que é porteiro do estabelecimento comercial e estava monitorando o local no momento em que percebeu o furto. Explicou que o sistema de monitoramento eletrônico também abrange a parte externa do Super Centro do Boqueirão. Assim, conseguiu perceber a subtração por meio das imagens das câmeras de segurança. Disse que observou quando um dos indivíduos arrancou uma das folhas da porta de alumínio do registro de água e tentou deixar o local rapidamente. Em seguida, informou seu companheiro de serviço e conseguiram deter essa pessoa na esquina do estabelecimento comercial, entre as Ruas Lobo Viana e Alvares de Azevedo. O outro envolvido deslocava-se naquela direção carregando a outra porta de alumínio. Explicou que permaneceu contendo aquele primeiro indivíduo, enquanto seu colega Alex interceptou o outro. Em audiência virtual, reconheceu acusado como um dos envolvidos. Acredita que o acusado não foi o indivíduo que conteve na ocasião. Disse que os dois detidos estavam em posse das duas folhas de alumínio. Afirmou que as portas ficaram danificadas em razão da subtração, mas puderam ser reinstaladas. Somente uma das folhas do portão foi levada até a delegacia. Não conhecia os furtadores. Informou que eles tentaram fugir e tiveram que imobilizá-los. Eles não deram explicações. Esclareceu que um dos furtadores foi por eles abordado na esquina, enquanto o outro ainda estava no meio da quadra da Rua Lobo Viana. Não se recorda se um deles tentou dispensar o objeto. Explicou que o jardim externo também pertence ao Super Centro do Boqueirão. Recorda-se que o agente abordado na esquina possuía barba e sua estatura era menor em relação ao outro envolvido. Não se recorda dos nomes dos acusados. Acredita que o réu presente em audiência se trate da pessoa abordada por seu colega (gravação audiovisual, pp. 206/208).

Alex de Oliveira Alves relatou que trabalha como porteiro do Super Centro do Boqueirão. Na data dos fatos, por volta de 1h, enquanto realizavam a troca de funcionários no setor de monitoramento, pelas câmeras viu dois indivíduos subtraindo um portão da área externa do estabelecimento comercial. Disse que abordaram os dois envolvidos com os portões nas mãos. Explicou que se tratava de duas portinholas de alumínio que guardavam o registro de água e ambas foram arrancadas do local de instalação. Esclareceu que o réu foi detido mais próximo do local da subtração, enquanto o outro já havia se distanciado. Disse que, ao perceber que seu comparsa foi detido, o acusado arremessou o portão que carregava no gramado, na tentativa de se livrar do flagrante. Ambos foram vistos enquanto estavam com os portões em mãos. Não conhecia nenhum deles até então. Afirmou que os criminosos justificaram o ato dizendo estarem com fome. Informou que a caixa de registro de água se situa na Rua Lobo Viana, onde os dois agentes foram abordados. Enquanto o corréu Ray estava próximo à esquina com a Rua Alvares de Azevedo, o acusado Rafael estava a cinquenta metros de distância do hidrômetro. Disse que o vigilante Américo estava no monitoramento e foi quem o informou sobre a subtração. Não viu as imagens posteriormente. O furto ocorreu no exato momento em que realizavam a troca de turnos do setor de monitoramento. Explicou que apresentaram apenas uma folha do portão à autoridade policial, pois fizeram com que o réu reinstalasse a outra no devido local. Ambas as portinholas puderam ser reutilizadas (gravação audiovisual, pp. 206/208).

Elias de Omena Gomes Oliveira, policial militar, declarou que via rádio foram acionados para atender uma ocorrência na qual dois indivíduos haviam sido detidos durante a prática de furto de um portão do Super Centro do Boqueirão. Não presenciou a subtração e, no local do crime, encontraram os acusados contidos pelos seguranças. Os responsáveis pela empresa informaram que os dois foram flagrados

subtraindo os portões de alumínio que protegiam o relógio de água do local. Sua equipe conduziu os envolvidos até a delegacia de polícia. Esclareceu que se tratava de duas folhas de alumínio. Conforme informações dos vigilantes, uma delas havia sido retirada e estava sendo levada por um dos agentes, enquanto o segundo criminoso ainda tentava arrancar a outra folha de alumínio quando foi surpreendido. Informou que conversou com os acusados e eles admitiram a subtração. Não os conhecia (gravação audiovisual, pp. 206/208).

Vê-se assim, que o contexto probatório aqui amalhado se revela coerente, harmônico e uníssono, dando ensejo ao desate condenatório.

Os depoimentos são seguros e não há contradição capaz de retirar o valor do contexto probatório, que revela que a confissão manifestada pelo réu na fase judicial não poderia ser desprezada.

Sob o crivo do contraditório, o representante da vítima, Américo, declarou que, por meio das imagens das câmeras de monitoramento, observou o momento em que o acusado e seu comparsa furtavam as portinholas metálicas que guarneciam o hidrômetro localizado na parte externa do estabelecimento comercial em que trabalha como porteiro.

Relatou que acionou seu colega Alex e foram ao encalço de um deles, que estava em fuga e na posse de uma das folhas de alumínio, detendo-o ainda na Rua Lobo Viana, esquina com a Rua Alvares de Azevedo. Em seguida, visualizaram o segundo envolvido carregando a outra parte do portão e o funcionário Alex o deteve.

A testemunha Alex, em semelhante relato, informou que durante a troca de turnos do setor de monitoramento do Super Centro do Boqueirão, seu colega Américo o informou que duas pessoas estavam subtraindo as portinholas de alumínio da caixa do relógio de água.

Referiu que o corréu Ray foi detido na esquina com a Rua Alvares de Azevedo na posse de uma das folhas do portão. O acusado Rafael estava a cerca de cinquenta metros de distância do hidrômetro quando foi perseguido, vindo a arremessar no gramado do estabelecimento a portinhola de alumínio que havia arrancado do local. Ademais, o policial militar relatou que sua equipe foi informada via rádio acerca do furto no Super Centro do Boqueirão. Chegando ao local, encontraram os dois indivíduos já detidos pelos vigilantes. Após tomarem conhecimento dos fatos e ouvirem a confissão informal de ambos os acusados, conduziram-nos até a delegacia de polícia.

Por fim, o réu admitiu em juízo que ele e seu comparsa furtaram as portas de alumínio, pois pretendiam vendê-las para conseguirem comprar alimentos e passagens de ônibus com destino a outra cidade.

Desta forma, certo está que a confissão - manifestada sob o crivo do contraditório - encontra seguro conforto na prova aqui reunida, que indica o desate condenatório. Inegável que se tratou de subtração consumada, pois ambos acusados tiveram a posse da res, ainda que tenham sido abordados a poucos metros de distância do local do furto, destacando-se que as duas portas de alumínio já haviam sido arrancadas pelos acusados quando da chegada dos vigilantes.

Não se cogita de desclassificação para reconhecimento do crime tentado, como pretendeu a Defesa, e isso porque se considera consumado o delito quando o agente desloca ou remove a coisa, invertendo-lhe a posse, ainda que por breve período, sendo desnecessário, inclusive, que a posse seja tranquila, pacífica e desvigiada, segundo a teoria "amotio".

Neste sentido, é a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Tema 934 - REsp nº 1524450).

Colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"... A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes..." (HC 135674, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, processo eletrônico, DJe-218

divulg 11-10-2016 public 13-10-2016).

Além disso, adotando esse entendimento, aponte-se julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"... Entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que o delito de furto se consuma com o simples apossamento do bem subtraído pelo agente, independentemente da circunstância de que essa posse não perdure no tempo, em face de perseguição e recuperação do objeto furtado em favor da vítima (Tema de recursos repetitivos número 934 do STJ) - Sentenciado que conduzia o veículo subtraído da vítima no momento da abordagem - Recurso defensivo desprovido - Recurso ministerial provido, com reflexo nas penas." (TJSP; Apelação Criminal 0020693-59.2017.8.26.0050; Rel. Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/02/2021).

Outrossim, a qualificadora relativa ao concurso de pessoas é situação perfeitamente configurada, sendo forçoso reconhecer que o acusado Rafael e o corréu Ray estavam efetivamente ajustados entre si e deram cabo à execução do crime de furto.

Inegável, pois, o auxílio e cooperação empreendidos pelo acusado e seu comparsa, que naquela situação fática agiram com unidade de propósitos e perpetraram a subtração dos portões de alumínio.

E, como já se decidiu:

"...O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles que concorreram para o crime incidem nas penas a ele cominadas, pois é tido como coautor todo o agente que desempenha tarefa necessária ao êxito global da infração. Para a caracterização da coautoria no concurso de pessoas é necessário somente a colaboração do agente para o deslinde da prática delituosa, não se exigindo que todos os partícipes tenham consumado atos típicos de execução..." (TJSP; Apelação Criminal 1503167-16.2018.8.26.0229; Rel. Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 11/06/2020). Registre-se, ainda, que é de se reconhecer que caracterizada e comprovada está a ocorrência da causa de aumento de pena do repouso noturno, descrita na denúncia, por se tratar de madrugada, período em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da diminuição da vigilância exercida sobre a res. Note-se que é de se reconhecer a referida causa de aumento de pena ainda que o crime tenha ocorrido em estabelecimento comercial, justamente em razão da menor vigilância do bem durante o período do repouso noturno. Essa, certamente, a mens legis.

E, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REPOUSO NOTURNO. MAJORANTE. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, é aplicável tanto para o furto simples como para o qualificado e independe de o local do fato encontrar-se habitado ou não durante a execução do crime. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (AgRg no REsp 1726761/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)

Afora isso, destaque-se que não é caso de se afastar a incidência da majorante do repouso noturno sob o argumento de que a existência de câmeras de segurança excluiria a menor vigilância sobre a res.

A circunstância de o local possuir sistema de vigilância humana ou eletrônica, apesar de dificultar a prática de furtos, não impede, por si só, a consumação delitiva e, de igual modo, não exclui a vulnerabilidade da coisa durante o repouso noturno.

Nesse sentido, cabe o julgado:

"...A existência de monitoramento eletrônico e segurança patrimonial no local dos fatos não afasta a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno, circunstância esta que possui caráter objetivo" (TJ-MG - APR: 10317190087161001 Itabira, Relator: Glaucio Fernandes, Data de Julgamento: 01/07/2020, Câmaras Criminais / 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2020).

Ressalte-se, portanto, que é necessário dar aos fatos a adequada definição jurídica, procedendo-se à emendatio libelli, uma vez que os fatos corretamente

narrados na denúncia imputam ao réu a prática do furto qualificado praticado durante o repouso noturno.

Com efeito, ao que narra a denúncia, o crime ocorreu por volta de 1h, ou seja, durante a madrugada.

Desta forma, cabível a emendatio libelli, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, pois sem modificar a descrição dos fatos narrados na petição inicial, é de se dar nova e adequada definição jurídica à conduta do acusado, tipificando-a no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal.

E, por certo, não se cogita de conduta atípica, como pareceu ao ilustre Defensor, já que inaplicável à situação ora analisada o princípio da insignificância.

Não há como admitir que o furto seja socialmente tolerado porque subtraídos bens de pequeno valor (porta de alumínio avaliada em R\$ 100,00 - p. 13) ou porque a vítima não teve prejuízo financeiro com o crime.

Essa conduta exige pronta repressão estatal, uma vez que perceptível a gravidade desse proceder, exigindo-se submissão dos autores dessa espécie de conduta à sanção penal seja para realização dos valores sociais, bem como para adequada aplicação da lei e restabelecimento da ordem jurídica, abalada pelo comportamento considerado criminoso.

Na verdade, a invocada atipicidade em razão do princípio da insignificância seria causa supralegal de exclusão de ilicitude. Todavia, é de duvidosa caracterização, ainda que se trate de bem de valor reduzido, ou porque ausente prejuízo financeiro para a vítima diante da recuperação do bem subtraído.

"Não há falar em aplicação do Princípio da Insignificância no caso concreto. O valor da res não é ínfimo - sob o enfoque dos destinatários da norma - e devem ser levadas em consideração, sem dúvidas, as condições pessoais do acusado, reincidente. Hipótese em que o reconhecimento da bagatela importaria em verdadeiro estímulo ao crime. A incidência do Direito Penal dá-se em relação ao criminoso, à vítima e à sociedade, motivo por que a particular relação entre os dois primeiros não é a preponderante nos crimes de ação penal pública e não determina o que seja ínfimo ou bagatela. Sem dúvidas é um verdadeiro absurdo cingir-se o conceito de significância unicamente ao monetário quantum correspondente ou à ausência de efetivo prejuízo diante da restituição dos bens. É a coroação da valoração financeira estanque que, infelizmente, prepondera e infecta os valores de nossa pobre sociedade atual e começa a invadir as instituições. Reconhecimento da relevância penal da conduta" (Apelação Crime Nº 70054854203, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 25/02/2014).

"Não há falar-se em atipicidade da conduta. O pequeno valor da res furtiva, de per si, não importa na incidência do denominado princípio da insignificância. Basta rememorar o disposto no § 2º do artigo 155 do Código Penal, que faz referência ao "pequeno valor" da coisa subtraída, prevendo, se presentes outros requisitos, a possibilidade de substituição da pena de reclusão por detenção, a diminuição de um a dois terços ou a aplicação isolada da pena de multa. Não afasta a lei, portanto, a tipicidade da conduta quando o valor do bem subtraído é diminuto. Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão veiculada na impetração. Aliás, não se pode olvidar que a aludida causa de exclusão da tipicidade é supralegal, de sorte que há corrente jurisprudencial que não a reconhece. Nesse sentido vem decidindo esta C. Câmara: "Por sua vez, também não há que se falar em absolvição por crime de bagatela, posto que no direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de forma a excluir tal evento da tipicidade penal, sendo irrelevante o fato do bem subtraído ser considerado, para os fins penais, como sendo ínfimo ou desprezível." (TJSP - 14ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia. Ap. Crim. nº 990.08.089790-0, j. 05.03.2009, v.u.).

"...Também, não é caso de absolvição por atipicidade da conduta, diante da adoção do princípio da insignificância. Ora, subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, é furto. Quem assim age infringe a lei penal, violando uma regra básica de comportamento e quebra a harmonia que deve existir na sociedade. Não consta que tenhamos firmado um contrato social segundo o qual nos é permitido subtrair coisas alheias, desde que não muito valiosas ou de pequeno valor. O furto

é crime contra o patrimônio e, por isso, a coisa subtraída precisa ter algum valor econômico. Mesmo que considerado pequeno o valor da res, o que importa neste e em todos os casos semelhantes é o desvalor da conduta praticada pelo agente, a qual é típica, pois prevista na legislação penal em vigor como crime de furto. Portanto, a subtração de bens, mesmo que de pequeno valor, “não pode ser tida como um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social” (STJ Resp 828181/RS - Rel. Min. Laurita Vaz - DJU 6.8.2007, p. 654; HC 53139/PB - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJU 26.11.2007, p. 249). Como é sabido, não há crime sem lei anterior que o defina. Dizer qual conduta é crime é tarefa que cabe ao legislador, é o resultado de um juízo de valor que ele faz a respeito de determinadas condutas. Portanto, subtrair coisa alheia móvel, segundo a legislação em vigor, continua sendo crime de furto, dispositivo que nada tem de inconstitucional. Então, sendo crime, não há como deixar de aplicar a lei. E o juiz, principalmente, não pode ignorá-la negando-lhe aplicação. A previsão de sanções leves para crimes leves, ou a exclusão do crime por atipicidade da conduta, são tarefas que cabem exclusivamente ao legislador, que vem se desincumbindo de seu papel, como fez ao criar a figura do “crime de menor potencial ofensivo”, prevendo o reconhecimento de “crime privilegiado”, permitindo a substituição da pena corporal por restritiva de direito etc. Para CLAUDIA ROXIN o primeiro a falar no princípio da insignificância o Direito Penal não deve se preocupar com condutas incapazes de lesar qualquer bem jurídico porque se a finalidade da lei penal é tutelar um bem jurídico, quando a lesão, de tão insignificante, torna-se imperceptível, não será possível proceder-se ao enquadramento por absoluta falta de correspondência entre o fato descrito na lei e o comportamento iníquo realizado. Assim, os danos de nenhuma monta devem ser considerados fatos atípicos (in “Curso de Direito Penal”, de Fernando Capez, Saraiva, 2000, vol. 1, pág. 16). Segundo os léxicos, a expressão “insignificante” é sinônima de bagatela. Insignificante é o que nada significa, que não tem valor, é coisa sem importância, inútil. A expressão “nada” quer dizer coisa nenhuma, não existente, de nenhum valor, vã, nula (Constituição Federal dicionários Aurélio, Houaiss, Mirador, Silveira Bueno). Pois então, no caso em apreço, constata-se que não se trata da subtração de coisa insignificante; não se trata de um palito de fósforo, de um alfinete usado, de um prego, mas de diversos objetos de uso pessoal da vítima e uma ferramenta de trabalho, uma máquina “Makita”, que não foi recuperada. O valor total dos bens foi estimado em R\$ 134,10 (cento e trinta e quatro reais e dez centavos fls. 16/18). Portanto, não se pode dizer insignificante o crime praticado pela ré. Por derradeiro, caso o pequeno valor da res furtiva leve, sempre, à aplicação da insignificância e ao reconhecimento da atipicidade penal, não haverá tutela jurídica ao patrimônio de estabelecimentos comerciais que trabalham com miudezas, com armarinhos, ou seja, “lojinhas de turco”. Nesse teor a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser conferido o seguinte precedente: RHC 6.319/PR, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 23/06/97, p. 29.166. E faz-lhe coro vultosa jurisprudência: RT 587/428, 602/342, 703/351, 723/674, 728/614, 743/673 e 746/622”... (TJSP - 4ª Câmara Criminal - Rel. Des. Euvaldo Chaib - Ap. Crim. nº 0040857-21.2012.8.26.0050 - j. 25/02/14).

A conduta descrita na denúncia é típica e antijurídica, de modo que o Direito Penal deve ser aplicado não apenas para ressaltar a validade da norma em comento, mas também para coibir a reiteração criminosa.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório. Procede, portanto, a ação penal.

Passo à individualização da pena.

O acusado é reincidente específico, pois condenado definitivamente por roubo majorado e furto (autos n.º 0001966-77.2016.8.26.0635 - certidão de p. 38 e autos n.º 0003110-23.2015.8.26.0562 - certidão pp. 38/39).

Além disso, ostenta duas condenações definitivas antigas pelas práticas de roubo e furto qualificado (autos n.º 0036182-83.2011.8.26.0071 - certidão p. 40 e autos n.º 0007009-17.2009.8.26.0319 - certidões pp. 40/41 e 205), as quais, ainda que não

sirvam para configurar a agravante da reincidência, maculam sua vida pregressa e deixam claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento em prática criminosa.

Nestes termos, recentemente o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes...". (AgRg no HC 509.034/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

De outro lado, o réu confessou a prática da conduta criminosa.

Assim, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão dos maus antecedentes, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. Presente a circunstância agravante da reincidência, representada por duas condenações definitivas por furto e roubo, aumento a pena em 1/3 (um terço), uma vez que se trata de reincidência específica e por outro crime contra o patrimônio, o que não poderia ser desprezado.

Assim, fixo a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Consoante estabelece o artigo 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

No entanto, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda, majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência.

A respeito decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"... REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal. (RHC 141519, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, processo eletrônico dje-223 divulg 08-09-2020 public 09-09-2020).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas.

Outrossim, cabe observar que o réu ostenta maus antecedentes por crimes patrimoniais (roubo e furto), o que revela não ser suficiente a integral compensação entre as circunstâncias.

Afora isso, verifica-se a existência de duas condenações anteriores em desfavor do acusado, ambas aptas a configurar a reincidência, o que desautoriza a concessão da pleiteada compensação.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"... A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, se tratando de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade..." (HC 531.187/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)..." (AgRg no HC 663.271/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

"...Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência..." (AgRg no HC n. 626.637/SC, relator Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021)

Assim, presente a atenuante da confissão, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, verificada a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, já que se tratou de subtração praticada durante o repouso noturno, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

Apesar do quantum de pena aplicada, ante a reincidência representada por duas condenações por crimes patrimoniais (roubo e furto), e evidenciados os maus antecedentes também por delitos contra o patrimônio, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, face a reincidência específica.

Não havendo informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar RAFAEL SANTOS BITENCOURT, qualificado nos autos, à pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

O acusado viu convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. É certo que o fato aqui apurado desassossega a sociedade, compromete a paz social e desequilibra a ordem pública.

Assim, a prisão por sentença condenatória recorrível se revela necessária, seja para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, bem como para resguardo da ordem e paz públicas.

Lembre-se que o acusado se vê envolvido na apuração de crime cometido em concurso de pessoas e durante o repouso noturno. Outrossim, é reincidente específico em delitos de furto e roubo e possui maus antecedentes pelos mesmos crimes.

Desta forma, é forçoso reconhecer que essa situação não revela que seja ele pessoa de boa conduta social, mantendo vida desregrada e fazendo da criminalidade e do ataque ao patrimônio alheio o meio de vida.

Por final, necessário registrar que as medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para acautelar o procedimento, agora julgado nesta Instância, sendo forçoso reconhecer que, em liberdade, o acusado poderá por em risco a aplicação da lei penal, pois condenado a cumprir pena em gravoso regime.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de arbitrar a reparação dos danos, pois, diferentemente do pleito formulado pelo Ministério Público a p. 96, consta que a empresa não suportou prejuízos financeiros.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 23 de maio de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA